

1505307-57.2021.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... à materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação, eis que não houve apreensão de droga na residência de numeral 29 e não há elementos que indiquem associação entre os réus. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado e a desclassificação da imputação original para o crime de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505307-57.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505307-57.2021.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300993/2021 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 21210169 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 1572/21/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2300993 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL FERNANDES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE CAROLINE BUENO, vulgo "Daia" e MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", todos qualificados nos autos (fls. 48, 50 e 51, respectivamente), foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/06, acusados de terem, em período indeterminado, mas que perdurou até 04 de novembro de 2021, neste último dia por volta das 15h00, na Rua Sebastião Gonçalves Cruz, casas 29 e 81, Jardim

Figueira, nesta Cidade e Comarca de Amparo, se associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (vide aditamento - fl. 521).

ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE CAROLINE BUENO, vulgo "Daia" e MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", também foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusados de terem, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 17h30m, na Rua Sebastião Gonçalves Cruz, 81, Jardim Figueira, nesta Cidade e Comarca de Amparo, guardado e vendido 02 (duas) porções de "crack", pesando 0,15g, fazendo-o sem autorização em desacordo com a lei.

ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE CAROLINE BUENO, vulgo "Daia" e MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", ainda foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusados de terem, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 15h00m, na Rua Sebastião Gonçalves Cruz, 81, Jardim Figueira, nesta Cidade e Comarca de Amparo, guardado e mantido em depósito, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou qualquer forma de disseminação de uso, 757 porções de "crack", pesando 119,66g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com a lei (fls. 305/310).

Em audiência de custódia, a prisão flagrancial de ADENILSON, DIANE e MICHEL foi relaxada, frente a não homologação, mas, no mesmo ato, houve a decretação da prisão preventiva de ADENILSON e DIANE (fls. 58/60). MICHEL teve sua prisão preventiva decretada ao tempo do recebimento da exordial acusatória (fls. 316/317)

A denúncia foi recebida em 07.10.2021 (fl. 317).

Os réus foram regularmente citados (fls. 409, 410 e 413) e, por intermédio de seus D. Defensores, apresentaram respostas por escrito à imputação (fls. 454/465 e 544).

Aditamento da denúncia para correção de aspecto temporal (fl. 521), devidamente recebido (fl. 559 - item "01").

Não sendo o caso de julgamento in limine, com absolvição sumária de nenhum dos acusados, determinou-se a abertura de instrução probatória (fls. 559/560), ocasião em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de quatro testemunhas arroladas pela Acusação e de uma indicada pela Defesa, seguindo-se dos interrogatórios dos três acusados, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 671).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação dos três acusados, pelos três crimes, por nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitivas.

O D. Defensor do corréu MICHEL requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que o réu foi absolvido da acusação de tráfico em outros autos, cujo flagrante fundamentou o decreto de prisão preventiva exarado nestes autos. No mérito, defendeu a existência de nulidade quanto ao depoimento do GCM Maurício, invocando suposto desvio de função, além de deficiência no conjunto probatório, mormente ausência do encontro de entorpecentes no interior do imóvel em que estava o acusado, o que autoriza o decreto absolutório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado e teceu considerações a respeito da pena (fls. 685/693).

A D. Defensora dos corréus ADENILSON e DIANE, em combativas alegações, arguiu nulidade do mandado de busca e apreensão, notadamente quanto à emenda formulada, visando também abranger o imóvel de numeral 29, alegando a inexistência de "embasamento fático". No mérito, defendeu deficiência do conjunto probatório, notadamente em relação à materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação, eis que não houve apreensão de droga na residência de numeral 29 e não há elementos que indiquem associação entre os réus. Subsidiariamente, requereu o

reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado e a desclassificação da imputação original para o crime de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD). Por fim, teceu considerações acerca da dosimetria da pena e postulou a concessão de prisão domiciliar para a corré DIANE (fls. 708/723) .

Manifestação do Ministério Público sobre a prova acrescida (fls. 730/732).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade da infração está devidamente comprovada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 44/46 - vide certidão de fl. 566), constatação provisória (fl. 47), comprovantes do numerário apreendido e depositado (fls. 270 e 271), relatório elaborado pela polícia civil, ilustrado com fotos (fls. 286/296), bem como e, principalmente, pelos laudos dos apetrechos apreendidos (fls. 314/315 e 343/344) e do exame químico-toxicológico realizado nas substâncias entorpecentes (fls. 311/313).

Com efeito, o referido laudo, corroborando o respectivo auto de constatação provisória, confirmou tratar-se de cocaína, como princípio ativo do "crack", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 - SVS/MS.

Há, ainda, um link nos autos contendo filmagens armazenadas em vídeos, documentando anteriores investigações policiais (cf. certidão de fl. 668).

Nos autos em apenso, registrados sob nº 1505215-79.2021.8.26.0022 há decisões deferindo a busca e apreensão domiciliares (fls. 72/73 e 92/93).

Nessa oportunidade e, desde já, AFASTO a alegação de nulidade arguida pela Defesa (fl. 709), na medida em que a decisão de fls. 92/93 (apenso), autorizando a busca e apreensão domiciliar também no imóvel de numeral 29, daquele mesmo logradouro (Rua Sebastião Gonçalves Cruz, Jardim Figueira), foi exarada a partir do relatório elaborado pelo Setor de Investigações Gerais de Amparo (SIG) - (fls. 78/79 - apenso), contendo informações semelhantes e suficientes àquelas existentes no relatório anteriormente apresentado, ilustrado com fotos (fls. 04/10 - apenso), que embasou a decisão anterior autorizando a investida policial no imóvel de numeral 81 (fls. 72/73 - apenso).

A linha investigativa adotada pela Central de Narcóticos de Amparo foi a mesma, qual seja, o envolvimento dos ocupantes dos imóveis de numerais 29 e 81, daquela mesma rua, com o tráfico de drogas, indícios levantados a partir de "denúncias anônimas" e trabalho de campo, este marcado por campanhas realizadas no local, materializadas em fotos e filmagens.

Inexistindo razões para o deferimento da medida em relação a um dos imóveis e não para o outro, alinhado a presença dos requisitos legais estampados no art. 240, do CPP, as decisões, fundamentadas que se mostraram, não padecem de nulidade.

Outrossim, anoto que ao tempo do cumprimento das duas ordens, a participação do Comandante da Guarda Municipal de Amparo, Maurício Soares de Campos, diversamente do sustentado pelo D. Defensor (fl. 688), não macula o ato, cuja tese envolvendo a nulidade da prova também deve ser AFASTADA.

Com efeito, a representação e o cumprimento das ordens de busca e apreensão

judicialmente expedidas (art. 241, do CPP) foram corretamente aperfeiçoadas, dentro do campo de atuação afeto à Polícia Civil, conforme previsões constitucionais (art. 144, §4º, da CF/88) e legais (arts. 4º e 13, III, 242, todos do CPP).

E, dentro deste contexto, a Polícia Civil, quando não dispuser de efetivo e o caso reclamar atenção, principalmente em se tratando de dois imóveis alvos de buscas, pode solicitar apoio das demais forças da área de segurança pública, formando uma operação conjunta com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, sem que a coordenação desta "força tarefa" seja esvaziada.

Em suma, não há irregularidades procedimentais, passíveis de comprometerem a validade da prova, quando a Polícia Civil coordena uma operação e, nesta condição de responsável, conta com o suporte dos demais integrantes das forças de segurança.

Recomenda-se, ademais, leitura ao art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 13.022/2014 (fl. 699).

As autorias, em relação a um dos crimes de tráfico (dia 04.11.2022), se apresentou segura somente quanto ao corréu MICHEL. Vejamos

Clayton Luiz dos Santos, policial civil, relatou que "denúncias" recebidas noticiavam a prática do crime de tráfico na residência de numeral 81, por um casal, ADENILSON e DIANE. Investigações foram realizadas e durante elas observou-se que ambos pararam de comercializar drogas naquele imóvel de numeral 81, função agora assumida por MICHEL, que nele passou a residir, enquanto o casal continuou a traficar, agora na residência de numeral 29. Realizaram-se campanhas, com visualização de tráfico em ambos os imóveis, de forma concomitante. Na data do cumprimento do mandado judicial, o depoente atuou em ambos os imóveis, sendo localizadas 757 pedras de "crack", escondidas atrás do muro, além de R\$1.200,00, celulares, anotações e apetrechos. Os dois imóveis alvos das buscas dão acesso a um terreno, local em que foram encontrados os entorpecentes. Reconheceu a fotografia de fl. 293 como sendo aquela do numeral 81, sendo a cadeira nela indicada utilizada para facilitar a transposição do muro para o terreno, onde estão bananeiras, nas quais foram escondidas as pedras de "crack". Submetido à conferência aos vídeos constantes dos autos, o depoente reconheceu o imóvel filmado em ambos como sendo aquele de numeral 81, identificando as pessoas que nele aparecem como sendo usuários. Ao final, o depoente informou que MICHEL, após ser solto, tornou a ser preso em flagrante, por tráfico, naquele mesmo imóvel de numeral 81, novamente na companhia da adolescente.

Estevão Cassiano Cimenton, policial militar, relatou ter sido acionado pela polícia civil para dar apoio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em duas residências situadas na mesma rua. Permaneceu responsável pela segurança do imóvel de numeral 29, sobre o qual recaíam informações como "ponto" de venda de drogas, em cujo interior foram abordados ADENILSON, DIANE, além de Paulo, sendo encontrados pela polícia civil 04 ou 05 celulares, petrechos para embalo de drogas, anotações e R\$700,00 em dinheiro. A polícia civil reunia informações no sentido de que entorpecentes eram armazenados na parte de trás da residência, notadamente em um terreno, que permite acesso tanto àquela residência de numeral 29, como a uma outra, de numeral 81, de forma que, nesse terreno, com o auxílio dos cães farejadores da GCM, foram localizadas mais de 700 pedras de "crack". Já conhecia DIANE e ADEMILSON dos "meios" policiais, devido ao envolvimento deles com o tráfico.

Maurício Soares de Campos, Comandante da GCM, relatou que na data dos fatos conferiu suporte à polícia civil ao tempo do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Dirigiu-se até um dos imóveis alvo das buscas, de numeral 81, estando no local o acusado MICHEL e a namorada, uma adolescente. A polícia civil

contava com informações de que "eles" pulavam o muro do fundo da casa para pegar drogas. No interior do imóvel foi localizado certa importância em dinheiro, além de embalagens de "chup-chup", comumente utilizadas para embalo de "crack". No final do muro daquela residência havia uma cadeira posicionada para facilitar que o muro fosse pulado, em direção a um terreno. Então, cães farejadores da GCM foram acionados, vindo a localizarem grande quantidade de entorpecentes, em meio às bananeiras, tratando-se de 750 pedras de "crack". Submetido à conferência, reconheceu a fotografia de fl. 293, enfatizando que ao subir na cadeira indicada na imagem há acesso às bananeiras (14m34s). Conhecia MICHEL dos "meios" policiais.

Jonatas Rodrigues da Silva, ouvido ao lado do acusado ADENILSON, posto que ambos recolhidos no mesmo estabelecimento prisional (CDP de Jundiaí), confirmou que em determinada data foi abordado pelos policiais em poder de 01 pedra de "crack", estando na companhia de João Gabriel (outro usuário). Disse que ao tempo da abordagem estava com aquele entorpecente há uma hora e meia aproximadamente e, diferentemente do que relatou em solo policial (fl. 15 - apenso), negou tê-lo adquirido junto a um casal. Submetido à conferência às fotografias e filmagens constante dos autos, após confronto das roupas (bermuda e blusa), reconheceu sua pessoa nas imagens, mas negou estar naquele imóvel para adquirir entorpecentes, tendo justificado que ali deseja "pegar algo para comer" (sic).

João Gabriel, ouvido somente em solo policial (fl. 15 - apenso), confirmou a compra de drogas, por Jonatas, junto a um casal, sem declinar os nomes, por temer represálias.

Ivo Francisco de Oliveira Scalvi pouco contribuiu para a melhor elucidação dos fatos, relatando conhecer a ré DIANE, usuária de drogas.

Os réus foram interrogados.

Assim como havia feito em solo policial (fl. 15), em Juízo MICHEL negou os fatos, alegando que as drogas foram "plantadas", da mesma forma como ocorreu em data posterior, quando ele voltou a ser preso. Não tem qualquer vínculo com o casal ADENILSON e DIANE, conhecendo-os apenas de vista. Também não havia cadeira encostada no muro do terreno em que foram encontrados os entorpecentes. O dinheiro apreendido é fruto do seu serviço. Estava residindo naquele imóvel, há um mês. Quanto aos saquinhos apreendidos, disse que eram para fazer "geladinhos".

Adotando a mesma versão vista para o flagrante (fl. 14), em seu interrogatório judicial, ADENILSON negou os fatos. Alegou que após sair da prisão conheceu DIANE e "tirou ela das drogas" (sic), não conhecendo o corréu MICHEL. O dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho como pintor. Questionado, informou que os fundos do seu imóvel não têm acesso ao terreno em que teriam sido encontradas drogas.

Por fim, DIANE foi ouvida que negou tanto em solo policial (fl. 16), como em juízo, a prática dos fatos. Disse que mantém um relacionamento amoroso com ADENILSON, sobrevivendo prole, passando ambos a residirem no imóvel da genitora dele, de numeral 29. Indagada, disse já ter adquirido entorpecente no imóvel de numeral 81, comprando diretamente do réu MICHEL.

Pois bem. Este é o contexto probatório.

Desde a apresentação dos acusados, presos em flagrante, ao tempo da audiência de custódia, o caso reclamou atenção especial do Poder Judiciário, frente às peculiaridades que apresentava (fls. 215/221).

Reforçando a lisura das ordens judiciais emanadas para busca e apreensão domiciliares junto aos imóveis de numerais 29 e 81 daquele mesmo logradouro, ordem

que foi cumprida, com idoneidade e validade, pela polícia civil, contando com apoio da polícia militar e da GCM, notadamente com o uso dos cães farejadores, o cenário produzido revela a prática do crime de tráfico, no dia 04.11.2022, pelo acusado MICHEL, vinculado que estava às 757 pedras de "crack" encontradas no terreno. Objetivamente nos autos, temos que investigações prévias vinculavam, num primeiro momento, a prática do crime de tráfico no imóvel de numeral 81. A partir de "denúncias anônimas", o SIG de Amparo realizou campanhas e confirmou movimentação de usuários na porta daquele imóvel, abordando Jonatas e João Gabriel, após saírem daquela residência, em poder de pedras de "crack".

Em solo policial, ambos confirmaram a aquisição daqueles entorpecentes junto a um casal, sem, todavia, declinarem os nomes - fl. 15 do apenso, podendo ser aquele casal formado por ADENILSON e DIANE ou MICHEL e sua namorada adolescente (M.E.).

E, foi justamente junto sobre este imóvel (numeral 81) que recaem fotografias e filmagens que embasaram o relatório investigativo, propulsor da ordem de busca e apreensão emitida, de forma que, ao tempo do cumprimento, no interior do imóvel estavam MICHEL e sua namorada, sendo encontrado, ainda, embalagens de "chup-chup", comumente utilizadas para embalo de "crack".

Todavia, o que realmente chama a atenção são as fotografias de fl. 293, contando, uma delas, com a imagem de uma cadeira estrategicamente posicionada para viabilizar que o morador pule o muro - não se percebe outra função daquela mobília naquele lugar - a fim de alcançar, com mais rapidez e facilidade, acesso ao terreno limítrofe, no qual drogas, em grande quantidade, foram encontradas em meio às bananeiras existentes - pela foto observa que tal planta, conforme folhagem que suplanta a altura do muro, está "colada" naquele imóvel.

Assim, aquela cadeira, que não havia razões para serem colocadas pelos policiais no momento da investida no imóvel, serviria para viabilizar o acesso ao terreno baldio, na busca das drogas ou até mesmo de uma fuga rápida, se necessidade houvesse.

Lembro, ademais, que pouco tempo depois - menos de 10 dias -, não aproveitando o voto de confiança que lhe foi depositado, MICHEL foi detido em flagrante por ter vendido e estar guardando novamente porções de "crack", naquele mesmo imóvel (numeral 81).

E, ainda que tenha sido absolvido pela Instância Superior, revertendo condenação anterior suportada, o fundamento adotado pelo E. TJSP foi no sentido de que sua prisão não poderia ter ocorrido por guardas municipais, na forma em que, isolada e autonomamente, ingressaram na residência, não pelo fato de inocentá-lo pelo crime de tráfico, desvinculando-o dos entorpecentes apreendidos (vide v. acórdão de fl. 694/703).

Também é preciso lembrar que MICHEL foi já havia sido absolvido em outras três oportunidades, em todas acusadas por tráfico (fls. 663/667), não vingando a posição de "vítima de perseguição" que pretendeu instalar ao tempo do seu interrogatório judicial, lembrando que ele não apresentou qualquer elemento de prova que esvaziasse o cenário fático constatado pelos policiais ao tempo da sua prisão.

De outro canto, em relação ao imóvel de numeral 29, ao tempo das investigações constou que os policiais receberam informações de que nele também passou a ser desenvolvido o comércio ilícito de drogas.

Contudo, não há fotografias, filmagens, abordagens de usuários e, ao tempo da ordem do cumprimento do mandado de prisão, estando em seu interior ADENILSON e DIANE, atuais moradores da localidade, não houve o encontro de entorpecentes ou de outros materiais que os vinculassem àquela atividade mercantil espúria.

Lembro, ademais, não obstante o idôneo e eficaz depoimento dos agentes integrantes das forças da área de segurança, sempre prestigiado por este Julgador em seus pronunciamentos jurisdicionais, a melhor dinâmica envolvendo o imóvel de numeral 29 com aquela plantação onde foram encontrados entorpecentes poderia ser melhor retratada nos autos, porquanto a imagem de fl. 294, extraída do Google Maps, não transmite a segurança necessária.

Outrossim, constou dos depoimentos que o terreno onde foram encontradas as pedras de "crack" é grande, pertencente ao "Lar dos Velhos" e casas do local dão fundo para ele (a partir dos 08m) - principalmente aquela ocupada por MICHEL, a mais próxima da bananeira.

Por fim, além da ausência de provas quanto ao efetivo envolvimento do casal ADENILSON e DIANE com o tráfico, frente à ausência de nomes declinados pelos usuários Jonatas e João Gabriel, estabelecendo um cenário de dubiedade junto deles com o também casal MICHEL e a namorada adolescente, ainda deve ser pontuado ter sido mencionado em audiência a existência de notícias acerca do envolvimento de MICHEL com tráfico, mas não junto com ADENILSON e DIANE (a partir de 42m10s).

Em suma, encerrada a instrução, o conjunto probatório não se reveste da segurança exigida para vincular o casal ADENILSON e DIANE com as pedras de "crack" encontradas geograficamente em local distinta daquele em que estavam morando, além da ausência de elementos que os vinculassem à comercialização de entorpecentes no imóvel de numeral 81 ou com o réu MICHEL, junto a quem, inclusive, DIANE disse ter comprado drogas certa vez.

Assim, não há nos autos elementos afiançados, produzidos sob o crivo do contraditório, que autorizem atribuir ao casal, extreme de dúvidas, como se requer o sistema processual penal pátrio, vínculo com aqueles entorpecentes apreendidos, bem como à prática do crime de tráfico de drogas.

Verifico que apesar da ocorrência do crime, este julgador não está amparado por conjunto probatório satisfatório que dimensione a realidade autoral em relação a ambos, apta a autorizar a condenação deles.

Relevo, não se trata, por certo, perfilar a inocência de ADENILSON e DIANE, que inclusive contam com condenações anteriores pela prática do mesmo crime, mas, sim, admitir a fragilidade do conjunto probatório que norteia os presentes autos.

Idealizar que eles também praticaram o crime é plenamente possível, porém acaba aí o que se pode extrair do que examinado. Conjuguar, tal lição, no presente caso, se mostra inexequível, além de temerário.

Leciona, a doutrina penal, sobre os dois momentos em que a dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal de alguém nasce em um fato processual, e como deverá ser decidida: A) ao início da ação penal a dúvida determina o ajuizamento da demanda; B) ao final, sobrevivida a dúvida, impõe-se a absolvição.

Informador pelo princípio do "non liquet".

E, se pelos subsídios e pelas provas carreadas que compõem a instrução probatória a responsabilidade de um acusado mostrar-se deficitária para autorizar uma condenação, é caso de se aplicar o princípio "in dubio pro reo", norteador do processo penal, bem como garantia constitucional do estado de inocência.

Da mesma forma, quanto ao crime datado de 15.09.2022 - venda de duas porções de "crack" - não há provas seguras e convincentes de ter sido realizada por nenhum dos réus, nem mesmo MICHEL, haja vista não estar documentado nos autos desde quando ele

estava residindo naquele local com sua namorada – situação bem delineada somente a partir de novembro/22. Consequentemente, não há campo para reconhecimento do delito de associação para o tráfico.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação de MICHEL, pelo crime de tráfico datado de 04.11.2022, e a imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, da análise de sua Certidão de Eventos (fls. 663/667) verifico que muito embora o réu não conte com envolvimento criminal anterior, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas destaco que ele foi surpreendido guardando pedras de "crack", substância de elevado poder viciante e altamente lesiva a saúde.

Não seria preciso dizer que drogas como o "crack" afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais acelerada, podendo causar taquicardia, febre, pupilas dilatadas, suor excessivo e aumento da pressão sanguínea, além de insônia, ansiedade, paranoia, sensação de medo ou pânico, liberação da agressividade e, em alguns casos, podem aparecer complicações cardíacas, circulatórias e cerebrais (derrame cerebral e infarto do miocárdio), além de levar à destruição de tecido cerebral.

Não é à toa que médicos da Universidade de Bristol e do Conselho de Pesquisa Médica da Grã-Bretanha desenvolveram um novo sistema de classificação que, segundo eles, reflete melhor os riscos representados por cada droga, colocando a cocaína e seu derivado "crack", como a segunda mais perigosa.

A Revista Veja, em sua edição nº 2.222, ano 44, nº 25, datada de 22.06.2011, publicou uma reportagem rotulada como "As Prisioneiras do Crack", na qual tratou com propriedade os reflexos que o "crack" produz no viciado e, principalmente, em seus familiares.

"Para se recuperar do vício, o dependente precisa passar por um longo processo, que inclui internações, tratamento das doenças associadas, consultas frequentes com psiquiatra e psicólogos e atividades que ajudem a reinseri-lo na família e na sociedade. (...). Já os pais e as mães do crack raramente contam com ajuda, orientação e tratamento. Tendem a se afundar na dor, na raiva, na culpa e na vergonha". (p. 99)

Assim, frente à natureza das drogas majoro, então, a pena-base em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes.

Na derradeira fase, entendo, pelos elementos constantes dos autos, não ser o caso do reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Isto porque, para que tal figura privilegiada seja reconhecida, devem ser preenchidos os requisitos previstos na própria Lei e, no caso em apreço, o acusado demonstrava dedicação à atividade criminosa, notadamente a prática do crime de tráfico.

Frisa-se que a circunstância "dedicação a atividades criminosas" não depende de fatores como a reincidência ou maus antecedentes.

Nesse sentido:

"(...) Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, não obstante o paciente seja primário e possuidor de bons antecedentes, o Tribunal estadual afastou a aplicação da causa especial de diminuição, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, as quais o levaram a concluir que o acusado se dedicava a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico (...)" (STJ HC 297406 SP2014/0150910-1, 6ª T., rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16.10.2014).

"Bem se percebe que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. Com efeito, não revela quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada, o registro da apreensão de considerável quantidade de entorpecente 100 porções "já embaladas para a mercancia ilícita", em local conhecido como ponto de tráfico. Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confirmam-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012" (HC 169630 AgR/RS, Min. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 17/05/2019, p.m.v., com divergência sobre o conhecimento do HC). Na Segunda Turma da Suprema Corte também há entendimento firmado a esse respeito, conforme ilustra o seguinte trecho de ementa:

"4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida" (HC 154462 ED-AgR, Min. Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 30/11/2018, v.u.).

Desta feita, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias fáticas da prisão, levando-se em consideração a abordagem anterior, no mesmo local, sendo encontrado com ele entorpecentes da mesma natureza (cf. fls. 168/171, 173/179 e 180/185), não há se falar em fato isolado.

Efetivamente, o réu estava envolvido com atividade criminosa, à ela se dedicando.

As drogas, em elevada quantidade (757 pedras de "crack"), estavam sob sua completa vigilância, fato que não o permite classificá-lo como iniciante nesse hediondo comércio. A expressiva cifra que aqueles entorpecentes simbolizam demonstra vivência (se considerar que ele mesmo traficaria) ou confiança e respeito acumulado junto a terceiros (se guardava a pedido) nesse pernicioso mundo do crime, porquanto ser incomum que micro-traficantes sejam apreendidos com volume tão expressivo de entorpecentes, de forte potencialidade e alta procura no mercado de viciados.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[...]

3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]"

(STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14);

Sem dúvida, a confiança nele depositada revela que já contava com posição de destaque nessa repugnante atividade mercantil, até porque, solto nestes autos, em menos de 10 (dez) dias tornou a ser preso em flagrante, também acusado de tráfico, novamente guardando "crack" naquela mesma residência.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffoli.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

E, no caso em testilha, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o inicial FECHADO.

Ora, é de pronta inteligência que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, principalmente no caso do réu, acintosamente envolvido com o tráfico de drogas – envolvendo até mesmo adolescente (namorada). Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua.

NÃO há que se falar em aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para:

A) ABSOLVER os réus ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE CAROLINE BUENO, vulgo "Daia" e MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", todos qualificados nos autos, da imputação relativa ao crime previsto no 35, da Lei nº 11.343/06, fazendo-o com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas seguras para um decreto condenatório.

B) ABSOLVER os réus ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE

CAROLINE BUENO, vulgo "Daia" e MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", todos qualificados nos autos, da imputação relativa ao delito previsto no 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no tocante ao crime de tráfico datado de 15.09.2022, fazendo-o com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas seguras para um decreto condenatório.

C) ABSOLVER os réus ADENILSON DONIZETI DE LIMA, vulgo "Gordo" e "Casa Caída", DIANE CAROLINE BUENO, vulgo "Daia", ambos qualificados nos autos, da imputação relativa ao delito previsto no 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no tocante ao crime de tráfico datado de 04.11.2022, fazendo-o com fundamento no art. 386, V, do CPP, diante da ausência de provas seguras de terem concorrido para a infração penal.

D) CONDENAR o réu MICHEL FERNANDES, vulgo "Falcão", qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49, por infração ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade total de pena sopesada (art. 44, inciso I, CP), além de não ostentar aspectos subjetivos favoráveis (art. 44, III, do CP).

O réu permaneceu preso durante a instrução processual. E, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei e a garantia da ordem pública (art. 312, caput, cc. 313, ambos do CPP) - lembrando que ele foi solto e tornou a se envolver com drogas -, agora, frente ao édito condenatório, com elevada pena, a ser cumprida em regime prisional mais gravoso, com maior razão, deverá aguardar preso a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Recomende-se o réu MICHEL no local em que se encontra recolhido.

Em relação aos corréus ADENILSON e DIANE, absolvidos de todas as imputações, expeçam-se alvarás de solturas, com urgência.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Declaro o perdimento do valor em espécie apreendido no imóvel de MICHEL (numeral 81), conforme art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, liberando-se aquele encontrado no imóvel de ADENILSON e DIANE (numeral 29).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução (Súmula nº 716, do STF) e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA